

제62회 2차 디자인보호법 시험 총평

유시훈 변리사

안녕하세요 수험생 여러분, 유시훈 변리사입니다.

정말 고생하셨습니다. 이미 답안지는 제출이 되었습니다. 그러니 시험 생각은 너무 하지 마시고, 휴식기를 가지시면서 재충전의 시간을 가지시길 바라겠습니다.

이번 디자인보호법 시험은 상중하로 표현하자면, **중중상 정도**로 평할 수가 있겠습니다. 지엽적인 논점도 출제되지는 않았고, GS에서 대부분 다뤘던 논점이기 때문에 아주 어렵거나 난해한 문제는 없었다고 생각됩니다. 다만, 多논점의 문제들이 많아 빠르고 정확하게 논점을 추출한 뒤 답안을 작성하는 것이 마냥 쉽지는 않으셨을 것 같습니다. 디자인은 큰 논점이나 정답의 이탈만 없다면 FAIL을 주지는 않는 경향 속에 있으니 큰 틀에서 잘 작성하셨다면 너무 걱정하시지는 마시기 바랍니다.

문제를 받아 보고 짧은 시간에 검토하여 간략한 총평 및 예상 답안의 목차를 드리오니, 참고용으로 이용해주시면 감사하겠습니다.

[문제 1]

문제 1은 여러 논점을 다뤄야 하는 문제이기는 하나, 서로 논리적으로 연결되기 보다는 병렬적으로 출제하였기 때문에 논점만 잘 추출하셨다면 답안을 작성하실 수 있으셨으리라 생각되지만, 쉽지만은 않은 문제였다고 생각합니다.

설문(1)은 丙이 등록디자인 A와 유사한 디자인의 생산에만 사용하는 물품(부품)을 대여하고 있으므로 간접침해의 요건인 공용성과 전용성을 모두 만족하는 사안입니다. 따라서, **간접침해 여부에 대하여 논해주신 뒤, 이에 따라 등록권리자인 甲이 취할 수 있는 민형사상 조치**를 논해주시면 됩니다.

다만, 甲과 乙이 디자인권을 공유하는 경우이므로 **공유관계에 따른 제한 요소 여부**로서, 지분에 기한 단독 침해금지청구권 행사 가능, 손해배상청구권도 지분에 대해서만 인정, 필수적 공동심판청구(권리범위확인심판)도 논해주시고, **간접침해에 따라 침해되는 죄형법정주의에 비추어 불성립한다는 것**을 전제하여 논해주시면 좋았을 것 같습니다.

설문(2)는 전용실시권에 따른 다양한 법적 관계에 대하여 물어보았습니다. 우선 **“전용실시권의 설정계약”이 유효하였는지**가 문제됩니다. 甲과 乙은 공유관계라는 문제가 있습니다. 공유인 경우에는 단독으로 실시권을 설정할 수 없고 다른 공유자의 동의가 요구된다(제96조 제4항)는 것이 문제가 됩니다. 따라서, 동의를 받았을 경우에 한하여 전용실시권의 설정계약이 유효하다는 언급이 필요하겠습니다.

甲과 X의 법적 관계는 어떤 것을 논점으로 잡아야 할 지 애매한 부분이 있습니다. 첫번째는 일단 **“전용실시권의 발생”이 유효하게 이루어졌는지**가 문제가 됩니다. 잘 아시는 것처럼 전용실시권은 설정계약만으로 그 효력이 발생하지 않고, 등록으로 그 효력이 발생합니다. 따라서, 전용실시권의 설정등록에 있어서 계약당사자인 乙은 협조하겠지만 甲에게는 별도로 협조를 구할 필요가 있습니다. 다만, 설문(2)에서는 등록된 사정이 없음에도, “전용실시권 설정계약을 체결하였다. 전용실시권자 X는~”이라고 표현하고 있습니다. 이는 출제자가 설정계약에 더하여 등록한 것을 전제로 “전용실시권자”라는 표현을 사용한 것인지는 의문으로 남습니다. 따라서, 이에 대해서는 짧게 언급해야 하지 않을까 하고, “등록”에 관한 문제는 없다는 것을 전제한 뒤 나머지 법적 관계를 논해야 할 것으로 보입니다. 등록 문제와 공유에 따른 동의 문제가 해결이 되었다면, X는 적법한 전용실시권자가 됩니다. **甲은 전용실시권의 설정 범위 내에서는 실시할 권리가 없다는 것, 그러나 소극적 효력은 제한되지 않기 때문에 설문(1)에서 취하고자 하였던 간접침해에 따른 조치들은 취할 수 있다**는 것을 논해줄 수 있을 것 같습니다.

X-Y의 관계는 X가 적법한 전용실시권자이기 때문에 설정 범위 내에서는 독점적 권리를 가지므로 **Y에게 민형사상 조치를 취할 수 있다**는 점을 언급하시면 될 것으로 판단됩니다.

설문(3)은 丁이 유사한 디자인 A'를 출원했다가 신규성으로 거절된 이력이 있으며, 실시를 시작한 시점이 甲의 출원일은 지났으며 설정등록일은 지나기 전이고, 설정등록일 까지도 계속해서 실시하고 있다는 취지로 설문에서 언급하고 있으므로 **선출원에 따른 통상실시권(제101조 법정실시권)**이 문제되는 사안입니다. 여기에 더하여, 101조가 등장한다면 **자유실시디자인의 항변** 역시 논해주시면 좋겠습니다.

丁의 출원 시(2023. 3. 20.) 전에 존재하는 A'와 유사한 선행디자인이 존재하고 있었음을 신규성 거절에 따라 유추할 수 있고, 선행디자인은 등록디자인 A 이전에 공지된 디자인일 것이기에 출원 전 공지디자인과 유사한 디자인인 A'를 실시하는 것은 자유실시디자인에 해당하게 됩니다.

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재
2. 丙의 간접침해의 성립 여부 - 적극
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 성립요건
 - (3) 사안의 경우 - 성립
3. 설문(1)의 해결 - 甲의 丙에 대한 조치
 - (1) 사전적 조치
 - (2) 민사상 조치
 - (3) 형사상 조치 - 불가

II. 설문(2)에 대하여

1. 甲과 乙의 법적 관계
 - (1) 문제점 - 전용실시권의 설정계약의 유효성
 - (2) 공유자의 실시권 설정 제한(제96조 제4항)
 - (3) 사안의 경우
甲의 동의가 있었다는 전제 하에 전용실시권 설정계약이 유효함
2. 甲과 X의 법적 관계
 - (1) 문제점 - 전용실시권의 등록 협조, 전용권의 제한, 소극적 효력의 불제한
 - (2) 전용실시권의 효력발생요건(제98조 제1항 제2호)
 - (3) 디자인권의 효력 제한 여부
 - (4) 사안의 경우
 - 甲의 등록 협조가 있어야 유효한 X에게 전용실시권이 발생함.
 - 甲은 설정 범위에서 전용권이 제한되지만, 소극적 효력은 제한되지 않기 때문에 丙에 대해서는 얼마든지 조치를 취할 수 있음
3. X와 Y의 법적 관계
 - (1) 문제점 - 전용실시권의 효력
 - (2) 효력 범위
 - (3) 사안의 경우 - X는 Y에게 민형사상 조치를 취할 수 있음

III. 설문(3)에 대하여

1. 문제의 소재 - 침해의 성립요건상 제101조, 자유실시디자인의 항변 문제됨
2. 선출원에 의한 통상실시권(제101조) 성립 여부 - 적극
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 요건

- (3) 사안의 경우
- 3. 자유실시디자인의 항변 가부 - 적극
 - (1) 판례의 태도
 - (2) 사안의 경우
- 4. 설문(3)의 해결 - 제101조의 통상실시권의 존재와 자유실시디자인의 항변 가능하여 비침해 주장 담은 답변서 송부

[문제 2]

문제 2는 무조건 나온다고 말씀드렸던 최신 대법원 판례를 기반으로 하여 문제가 출제되었습니다. 많은 수험생 분들이 이 판례만큼은 잘 준비하셨을 거라 생각합니다. 제 실전 GS 문제로도 충분히 대비가 되었을 것 같네요 ;)

다만, 이 문제... 설문의 문장들이 다소 어색하게 기술되어 있어서 참 그렇습니다.

설문(1)은 문장이 다소 난해하게 기술되어 있습니다. “등록요건으로서 디자인의 동일 유사 여부, 등록디자인의 대상 물품인 ‘식품보관용 용기’에서의 유사 여부”를 논하라고 하였습니다. 어색한 문장이지만 출제자 의도를 최대한 해석해보아야지요. **저는 이 문장이 전자는 신규성과 선출원주의 등에서 다뤄지는 유사 판단에 대한 일반적인 내용과 판례들을 기재해보라는 식으로 읽히고, 후자는 여기에서 중점적으로 다뤄진 판례를 기재해보라는 것으로 읽힙니다.**

설문(2) 역시 乙이 상고심에서 주장한 것이 없는데 “乙의 주장이 받아들여질지 여부에 관하여 논하시오”라고 하고 있습니다. 이 사건은 대법원에서 뒤집힌 사건이고, 비유사로 소권심이 인용되었어야 하는데 계속 기각을 맞았으므로 **설문(2)에서 잘 사안포섭해서 결론을 내라는 것으로 읽힙니다.** 따라서, 설문(1)에서 최대한 풍부하게 단문들을 기재해 주어야 할 것으로 판단됩니다.

설문(1)은 우선 등록요건으로서의 유사 판단이라는 목차 하에 **유사 판단의 의의 및 취지, 물품의 유사 판단을 전제로 한다는 점, 기본적인 판례와 심사기준, 요부관찰의 법리** 정도를 기재하면 좋을 듯 합니다. 이어서, 식품보관용 용기에서의 유사 판단은 **공지된 일부 형상의 취급, 유사의 폭**에 대하여 논해주시면 되겠습니다. 여기서 사안포섭을 다 하기 보다는 식품보관용 용기의 공지된 부분들은 요부에서 제외하고, 식품보관용 용기와 같은 물품은 유사의 폭을 좁게 보아야 된다는 것 정도만 언급해주시면 될 것 같습니다.

설문(2)에서는 설문상의 모든 사실관계를 가져와서 비유사라는 결론으로 이르는 과정을 보여주시면 될 듯하고, 乙의 주장이 받아들여져 원심을 파기하고 환송한다는 결론을 내시면 될 것으로 보입니다. 배점을 위해 사전에 권리범위확인심판의 의의 및 취지와 확인의 이익 정도 간략하게 검토하면 좋을 것 같습니다.

I. 설문(1)에 대하여

1. 유사 의의 및 취지
2. 판단의 전제
3. 등록요건으로서의 동일, 유사 여부
 - (1) 문제되는 등록요건
 - 1) 신규성
 - 2) 선출원주의
 - (2) 디자인의 유사 판단 방법
 - 1) 전체관찰의 원칙(판례)
 - 2) 요부관찰의 병행(판례)
 - 3) 심사기준의 태도
4. '식품보관용 용기' 디자인의 유사 여부
 - (1) 공지된 일부 형상의 취급
 - (2) 유사 폭
 - (3) 사안의 경우 - 공지된 부분은 요부에서 제외하고, 유사 폭은 좁게 보아야

II. 설문(2)에 대하여

1. 권리범위확인심판의 의의 및 취지
2. 확인의 이익 - 확인대상디자인의 도면이 실제 사진인 것으로 보아 실시 또는 실시 예정인 것으로 보이므로 인정됨
3. 등록디자인 A와 확인대상디자인 B의 유사 여부 - 소극
 - 설문에서 언급한 공통점들은 이미 공지된 선행디자인 W, X에 존재하므로 요부에서 제외하여 판단하여야 함
 - 식품보관용 용기는 유사 폭을 좁게 보아야 함 -> 약간의 차이도 심미감이 다르게 느껴질 수 있음
 - 설문에서 언급한 차이점들은 유사 폭을 고려하여 봤을 때 전체적 심미감에 영향을 주는 차이이기 때문에 비유사함
4. 설문(2)의 해결 - 주장 받아들여져서 원심 파기환송

[문제 3]

문제 3 역시 문제 1처럼 다논점 문제이기는 하나, 거의 병렬적인 논점으로 침착하게 논점을 잘 뽑아주셨어야 하는 문제입니다. 긴장된 상황에서는 쉽지만은 않았을 문제입니다.

설문(1)은 식품디자인의 물품성과 공업상 이용가능성에 대하여 논하라는 간단한 문제였습니다. 물품성과 공업상 이용가능성에 대한 의의 및 취지만 간단하게 언급하고 심사기준의 판단기준을 기재한 뒤, 두 요건 모두 만족한다는 식으로 포섭하시면 됩니다.

설문(2)는 단서 조건에 선행디자인과 관계되는 것들은 제외되어 있기 때문에 숨겨진 논점을 찾아야 했습니다. 쿠키와 쿠키 형틀은 비유사하기 때문에 관련디자인으로 출원하기는 어렵겠습니다. 따라서, 주요 논점은 비유사한 디자인을 관련디자인으로 출원함에 따른 35조 1항 위반의 거절이유가 존재한다는 것, 다른 등록요건 문제가 없다면 이는 48조 2항의 보정으로 극복이 가능하다는 것입니다.

설문(3)이 다소 생소하게끔 기술된 문제입니다만, 들여다보면 실상은 풀어본 문제입니다. 배점이 18점으로 매우 크고, 논점은 이용관계와 저촉관계로 주어진 상황이기 때문에 일단 단문을 잘 기재하고, 소설문 2개에 대하여 나름 논리적으로 답변을 내면 되는 문제입니다.

디자인 B의 출원일이 2023. 10. 12.이고, 특허발명 X와 Y는 2023. 8. 13.에 출원하였기 때문에 특허가 선출원인 상황에서 모두 등록되었기 때문에 특허발명 X와 Y를 이용하거나 양자가 저촉관계에 있을 수 있는 상황이겠습니다.

설문을 자세하게 읽어보면 디자인 B와 유사한 디자인이 아니라 디자인 B가 문제되는 상황이기에 95조 1항이 주요 논점이라고 보시면 되겠습니다. 특허발명 X는 디자인 B의 일부 구조를 청구항에 기재한 것으로 보이고, 특허발명 Y는 디자인 B의 전체 구조를 청구항에 기재한 것으로 보입니다. 디자인 B를 실시하면 특허발명 X, Y를 모두 실시하게 되고, 특허발명 X를 실시하면 디자인 B를 실시하는 것이라고 보기는 어렵고, 특허발명 Y를 실시하면 디자인 B를 실시하는 것이라고 볼 수 있습니다. 즉, 甲의 생각대로 X와는 일방적 충돌관계, Y와는 쌍방의 충돌관계가 발생하고 있는 상황이어서 각각 이용관계, 저촉관계가 성립하는 상황이라고 볼 수 있습니다.

디자인 B를 실시하기 위해서는 乙의 허락이나 통상실시권허락심판이 필요한 상황이라고 보시면 되겠습니다.

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재 – 식품디자인의 특성에 기초하여 물품성, 공업성 논의
2. 디자인 A의 물품성 인정 여부 – 적극
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 식품디자인의 경우
 - (3) 사안의 경우
3. 디자인 A의 공업성 인정 여부 – 적극
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 식품디자인의 경우
 - (3) 사안의 경우

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재 – 35조 1항, 48조 2항
2. 35조 1항 위반 여부 – 적극
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 쿠키와 쿠키 형틀의 유사 여부 – 비유사
 - (3) 사안의 경우 – 위반
3. 설문(2)의 해결 – 등록을 위한 조치
 - (1) 48조 2항
 - (2) 사안의 경우 – 관련디자인을 단독디자인으로 변경하는 보정서 제출

III. 설문(3)에 대하여

1. 문제의 소재 – 이용관계, 저촉관계 (95조 1항)
2. 이용관계
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 성립요건 – 적선타포
 - (3) 판단방법 – 비요본그필
3. 저촉관계
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 성립요건 – 권리범위의 중첩이 다른 점
4. 소설문 1)의 해결
 - (1) 이용관계 성립 여부
적법 등록 / 선등록 특허발명 / 타인 / X 권리범위를 포함함
 - (2) 저촉관계 성립 여부
적법 등록 / 선등록 특허발명 / 타인 / Y 권리범위와 중첩됨

5. 소설문 2)의 해결

- (1) 이용 저촉관계의 효과 - 적극적 효력의 제한
- (2) 사안의 경우 - 허락 / 통실히 필요

[문제 4]

문제 4는 꽤 쉬운 사례였지만, 4번 마지막 문제인 점에서 논점 누락이 있으셨을 수도 있을 것 같습니다. 주요 논점은 신규성, 재출원 및 조약 우선권 주장입니다. 신규성 상실의 예외는 살짝만 언급하면 좋지 않을까 생각합니다.

설문(1)은 8점이기에 배점 조절이 필요했던 문제입니다. 신규성 단문을 너무 길게 적어서는 안되겠죠. 이런 쉬운 문제는 문제에서 준 사안을 충실히 포섭해주는 것이 중요합니다. 국외의 공지디자인도 인용대상이 될 수 있고, 디자인공보에 게재된 것은 “반포된 간행물의 게재”로, 인터넷 쇼핑몰 업로드 광고는 “전기통신회선을 공중에 이용 가능하도록 제공한 것”, 판매행위는 “공지 또는 공연 실시”에 해당하는 행위라는 것을 사안포섭에 잘 적어주셔야 하겠습니다.

설문(2)는 신규성 상실의 예외에 대해서는 간단하게 한 문단으로만 논해주시면 좋을 것 같습니다. 간략하게 인터넷 쇼핑몰 업로드 광고나 판매 행위는 그 대상이 될 수 있겠으나, 중국의 디자인 공보에 게재된 것은 그 주장의 대상이 될 수 없기 때문에 신규성 상실의 예외 주장으로는 신규성 위반 사유를 극복하기 어렵다는 정도이면 충분합니다.

따라서, 이를 극복하기 위해서는 조약우선권주장을 통해 판단시점을 소급받아야 하겠습니다. 그러나, 조약 우선권 주장을 출원 시에만 할 수 있고, 아예 주장하지 않았을 때에는 그 추가하는 보정도 어렵기 때문에 현재 출원에서는 주장이 불가하고, 재출원이 요구됩니다. 즉, 2025. 9. 5.까지 재출원 및 조약우선권주장을 한다면 디자인 A를 대한민국에서도 등록받을 수 있겠습니다.

I. 설문(1)에 대하여

- 1. 신규성의 의의 및 취지
- 2. 판단 방법 - 국제주의라는 점도 반드시 포함
- 3. 신규성 상실 사유
 - (1) 공지, 공연 실시
 - (2) 반포된 간행물에 게재
 - (3) 전기통신회선을 통해 공중이 이용 가능하도록 제공
- 4. 설문(1)의 해결

국외의 공지디자인도 인용대상이 될 수 있고, 디자인공보에 게재된 것은 “반포된 간행물의 게재”로, 인터넷 쇼핑몰 업로드 광고는 “전기통신회선을 공중에 이용 가능하도록 제공한 것”, 판매행위는 “공지 또는 공연 실시”에 해당하는 행위이므로 신규성 위반에 해당함

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재 – 신상예 주장 가부, 조약우선권주장
2. 신규성 상실의 예외 주장 가부 – 불가 (한문단으로 처리)
3. 조약 우선권 주장 가부 - 불가
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 요건 및 절차
 - (3) 효과
 - (4) 사안의 경우 – 추가는 불가능하기 때문에 현재 출원에서는 주장 불가함.

4. 설문(2)의 해결

- 신상예는 디자인공보 게재로 어려움
- 따라서, 2025. 9. 5.까지 재출원 및 조약우선권주장의 취지를 기재하고, 출원일로부터 3개월 이내에 중국 출원에 대한 증명서류를 잘 제출하는 경우에는 판단시점이 소급되어 신규성 위반의 사유를 모두 극복할 수 있음.